



GUIA DE ESTUDO

DIREITO

• TEMA 2 •

FENOMENOLOGIA — IMAGENS
E PERSPECTIVAS DO DIREITO



01 FENÓMENO
JURÍDICO



02 IMAGENS
DO DIREITO



03 PERSPECTIVA
NORMATIVA



04 PERSPECTIVA
SOCIAL



05 PERSPECTIVA
INSTITUCIONAL



06 PLURALIDADE
DE OLHARES



O direito revela-se de modos distintos
conforme o olhar que o interroga.



INTRODUÇÃO AO DIREITO

TEMA 2

FENOMENOLOGIA

Imagens e perspectivas do Direito

IMAGEM PROFANA • VISÕES EXTERNAS • AUTOGNOSE

ROTEIRO DE ESTUDO

O que tens de dominar

Objetivo	No final, deves conseguir...
1	Explicar a imagem profana do Direito e os seus limites.
2	Reconhecer a onnipresença quotidiana e a função protetora do Direito.
3	Interpretar imperatividade, coercibilidade, generalidade, abstração, hipoteticidade e violabilidade.
4	Comparar imagens intelectualizadas externas e perspectivas internas.
5	Distinguir Direito positivo, Direito vigente e Direito natural.
6	Confrontar positivismo e jusnaturalismo sem os reduzir a caricaturas.
7	Responder de forma estruturada à questão proposta na AF2.

Mapa do tema

Capítulo	Percurso
I	Imagem profana e onnipresença quotidiana
II	Imagens e visões intelectualizadas
III	Perspetivas intrajurídicas e autognose

Questão central
O que se entende por Direito Natural e Direito Positivo?

OBSERVAR COMO O DIREITO APARECE

Fenomenologia jurídica

A fenomenologia parte das manifestações do Direito: como é vivido, percebido e representado. Em vez de começar por uma definição fechada, compara imagens sucessivas e pergunta o que cada uma revela ou oculta.

Nível de observação	Quem olha?	O que tende a ver?
Profano	Cidadão sem formação jurídica	Ordem, comando, proibição, polícia e sanção
Intelectualizado externo	Filósofo, sociólogo, politólogo, economista	Valor, poder, facto social, ideologia ou instrumento
Intrajurídico	Jurista e pensamento jurídico	Fontes, validade, sistema, Justiça e correntes doutrinárias

Método de leitura

- Identificar o ponto de vista.
- Reconhecer a parcela de verdade que contém.
- Detetar a redução ou o preconceito.
- Integrar a perspetiva numa imagem mais completa.

Ideia-chave

Uma imagem parcial não é necessariamente falsa; torna-se enganadora quando pretende explicar todo o fenómeno jurídico.

CAPÍTULO I - IMAGEM PROFANA

Imperatividade e coercibilidade

No entendimento comum, o Direito surge como conjunto de regras que exige, proíbe e impõe. A sanção e a força institucional parecem ser os seus traços mais visíveis.

Conceito	Significado
Imperatividade	A norma apresenta uma conduta como devida, proibida ou permitida dentro de uma ordem.
Coercibilidade	Possibilidade de recorrer à força institucional para garantir o Direito ou reagir à violação.
Coação	Uso efetivo dessa força num caso concreto.
Sanção	Consequência jurídica associada à infração; pode punir, reparar, invalidar ou compelir.

Porque esta imagem domina

- A obrigação é sentida quando limita uma intenção.
- A sanção torna-se saliente perante a violação.
- Conflitos e crimes recebem maior visibilidade pública.

Limite

Se o Direito fosse apenas comando e força, seriam invisíveis as suas funções de reconhecimento, proteção, prevenção e organização.

PATOLOGIA E FISIOLOGIA

A violação torna o Direito visível

Patologia jurídica	Fisiologia jurídica
Infração, litígio, dano e sanção	Cumprimento espontâneo e funcionamento regular
O Direito aparece como reação	O Direito atua como estrutura prévia
Conflito trazido ao tribunal	Relações estabilizadas sem conflito
Reparar ou punir	Prevenir, reconhecer e organizar

A proteção existe antes da violação

Um direito de propriedade não nasce quando o bem é danificado. Já existia, atribuía uma posição ao titular e impunha aos demais um dever de respeito. A ação judicial e a reparação tornam visível uma tutela anterior.

Sequência jurídica

Fluxo

Atribuição de um direito → dever correspondente → eventual violação → ação → tutela ou sanção

- Quem tem um direito dispõe, em regra, de mecanismos para o proteger.
- A infração não esgota o Direito: pressupõe uma ordem já constituída.
- A função preventiva é menos espetacular, mas mais constante.

OMNIPRESENÇA QUOTIDIANA

O Direito protetor e discreto

O Direito acompanha atos rotineiros sem ocupar a consciência dos sujeitos. Comprar um café, usar transportes, arrendar uma casa ou utilizar água e eletricidade envolve contratos, direitos, deveres e garantias.

Situação quotidiana	Dimensão jurídica
Comprar um café	Proposta, aceitação, prestação, preço e proteção do consumidor
Viajar de autocarro	Contrato de transporte, segurança e responsabilidade
Habitar uma casa	Propriedade ou arrendamento, privacidade e serviços essenciais
Trabalhar	Estatuto profissional, direitos, deveres e limites do poder
Participar politicamente	Cidadania, liberdade, voto e organização institucional

Direitos e papéis

O Direito reconhece direitos e estabelece estatutos: a mesma pessoa pode ser mãe, filha, trabalhadora, advogada, eleitora e membro de uma associação. Cada papel cria relações jurídicas específicas.

Dupla face

O Direito impõe incómodos e oferece comodidades: exige deveres e, simultaneamente, protege posições e expectativas.

PARA ALÉM DA FORÇA

Características da norma jurídica

Característica	Leitura
Generalidade	Destina-se a todos os sujeitos que preencham uma categoria.
Abstração	Regula tipos de situações, não apenas um episódio irrepetível.
Hipoteticidade	Liga uma consequência à verificação de certos pressupostos.
Violabilidade	Pode ser desobedecida; a norma não elimina a liberdade humana.
Imperatividade	Exprime uma exigência da ordem jurídica.
Coercibilidade	Admite garantia institucional contra a violação.

Liberdade como pressuposto

A norma jurídica dirige-se a pessoas capazes de escolher. Se a conduta fosse mecanicamente inevitável, não faria sentido imputar responsabilidade ou prever sanções. No limite, sem liberdade não há Direito.

Exemplo de hipoteticidade

Se alguém preencher os pressupostos previstos na norma, então se produz a consequência jurídica correspondente.

DO OLHAR LEIGO AO OLHAR TEÓRICO

Capítulo II - Visões intelectualizadas

Fora da experiência profissional dos juristas, o Direito é frequentemente interpretado por categorias de outros saberes. Essas leituras ampliam a compreensão, mas podem reduzir o jurídico a um único fator.

Perspetiva	O que revela	Redução possível
Sociológica	Factos sociais, práticas e eficácia	Direito = comportamento observado
Política	Poder, decisão, conflito e autoridade	Direito = vontade do poder
Económica	Escassez, incentivos e custos	Direito = instrumento de eficiência
Filosófica	Fundamentos, validade, valor e Justiça	Abstração desligada da prática
Ideológica	Interesses e estruturas de dominação	Direito = mera superestrutura

Problema do exterior

Quem observa de fora pode não possuir a experiência interna do Direito; quem observa de dentro pode ficar condicionado pelos seus hábitos. A compreensão exige diálogo entre ambos.

UMA VERDADE INSUFICIENTE

Definições correntes e legalismo

Uma definição empírica tende a apresentar o Direito como disciplina da conduta humana, imposta e exigível pela comunidade, destinada à convivência e à Justiça. O positivismo legalista acentua a produção estatal e a norma posta.

Afirmação	Parcela de verdade	Insuficiência
«Direito é lei.»	A lei é fonte central nos sistemas atuais.	Há princípios, costumes, decisões e interpretação.
«Direito é ordem.»	Coordena expectativas e condutas.	Uma ordem arbitrária pode negar o jurídico.
«Direito é sanção.»	A tutela pode recorrer à força.	Muito Direito é cumprido e protetor.
«Direito é o que o Estado impõe.»	O Estado garante grande parte do Direito positivo.	Validade formal não resolve a legitimidade.

Dois desvios opostos

- Burocratismo: venerar lei e regulamento como fins em si mesmos.
- Conveniência: aplicar rigor aos outros e exceções aos próximos.

Critério

A segurança jurídica exige regras estáveis e aplicação imparcial; a Justiça impede que a legalidade se converta em puro formalismo.

O DIREITO VISTO POR SI PRÓPRIO

Capítulo III - Autognose jurídica

A autognose é o esforço do pensamento jurídico para conhecer a natureza, os fundamentos e os limites do próprio Direito. As perspectivas internas também divergem e refletem paradigmas.

Pergunta	Possíveis respostas
O que conta como Direito?	Normas postas; práticas efetivas; princípios de Justiça
Porque vale uma norma?	Criação competente; pertença ao sistema; legitimidade material
Como decidir?	Aplicação sistemática; interpretação; argumentação e prudência
Qual o fim do Direito?	Ordem, segurança, paz, liberdade e Justiça
Pode uma lei ser antijurídica?	O positivismo e o jusnaturalismo respondem de modo diferente

Três conceitos necessários

- Direito positivo: Direito posto ou efetivo numa comunidade.
- Direito vigente: Direito positivo que está atualmente em vigor.
- Direito natural: princípios de Justiça que fundamentam e permitem criticar o Direito posto.

Atenção

«Positivo» não significa bom; significa posto, reconhecido ou efetivo numa ordem histórica.

O DIREITO QUE É

Direito positivo

Aspeto	Caracterização
Origem	Manifestação de vontade social ou de autoridade segundo processos reconhecidos
Forma	Normas, princípios, decisões, costumes e outras fontes admitidas
Âmbito	Uma comunidade, território e período determinados
Garantia	Instituições públicas e mecanismos de tutela
Vantagem	Segurança, previsibilidade, objetividade e coordenação
Limite	Pode conter soluções formalmente válidas, mas materialmente injustas

Direito vigente

É a parcela do Direito positivo que vale no presente. Uma norma revogada continua a ser Direito positivo histórico, mas já não é Direito vigente.

Legalidade e legitimidade

- Legalidade: conformidade com as regras e competências do sistema.
- Legitimidade: justificação do conteúdo à luz de valores e princípios.

Exemplo

Uma pena prevista por lei pode ser legal naquele sistema e, ainda assim, ser contestada como ilegítima por violar o direito à vida.

O DIREITO QUE DEVE SER

Direito natural

O jusnaturalismo afirma que o Direito não se esgota nas normas postas: existem critérios superiores de Justiça capazes de fundamentar, orientar e criticar a legislação.

Aspeto	Caracterização
Fundamento	Natureza humana, razão, dignidade, ordem natural ou outra base primordial
Pretensão	Universalidade para além de um Estado ou momento histórico
Função	Avaliar a Justiça das leis e limitar o poder
Expressão atual	Princípios e direitos fundamentais, como vida, igualdade e liberdade
Vantagem	Impede que validade formal seja confundida com Justiça
Risco	Apresentar convicções morais ou religiosas particulares como universais

Positivização de princípios

Muitos princípios associados ao Direito natural foram incorporados nas constituições. Tornam-se, assim, simultaneamente ideais de Justiça e Direito positivo vigente.

Ideia-chave

O Direito natural pergunta pelo fundamento e pelo dever-ser; o Direito positivo identifica o Direito efetivamente posto.

COMPARAÇÃO ESSENCIAL

Positivismo e jusnaturalismo

Critério	Positivismo	Jusnaturalismo
Pergunta central	Que Direito existe e é válido?	Que Direito é justo e deve valer?
Referência	Fontes postas e critérios do sistema	Princípios superiores de Justiça
Força	Segurança e previsibilidade	Crítica da lei injusta e do arbítrio
Risco	Legalismo e conformismo perante o poder	Indeterminação e confusão com moral/religião
Lei injusta	Pode continuar juridicamente válida	É defeituosa ou, no limite, não é verdadeiro Direito

O lugar híbrido

O jurista precisa de conhecer rigorosamente o corpo do Direito positivo para garantir segurança jurídica, mas deve conservar como horizonte a realização da Justiça. A síntese não apaga a tensão; transforma-a em responsabilidade profissional.

- Sem positividade, o ideal pode não ter eficácia institucional.
- Sem Justiça, a positividade pode tornar-se instrumento da força.

Fórmula de equilíbrio

Corpo da lei + interpretação responsável + horizonte de Justiça.

DIREITO NATURAL E DIREITO POSITIVO

Construir a resposta à AF2

Etapas	Conteúdo esperado
1 - Introdução	Apresentar as duas posições clássicas e a tensão entre ser e dever-ser.
2 - Direito positivo	Definir, indicar origem, âmbito, garantia, vantagens e limites.
3 - Direito natural	Definir, explicar fundamento, universalidade e função crítica.
4 - Comparação	Confrontar validade, Justiça, legalidade e legitimidade.
5 - Exemplo	Usar uma lei formalmente válida contestada à luz de um direito fundamental.
6 - Síntese	Defender segurança jurídica com horizonte de Justiça.

Resposta nuclear

O Direito positivo é o conjunto de normas e princípios efetivamente postos numa comunidade e garantidos institucionalmente; o Direito natural designa princípios superiores de Justiça, considerados inerentes à pessoa ou racionalmente universais, que fundamentam e permitem avaliar o Direito posto.

Evita

- Dizer que Direito positivo é sempre justo.
- Confundir «positivo» com «vantajoso».
- Reduzir Direito natural a uma lei escrita.
- Apresentar moral e Direito como realidades idênticas.

TESTA O DOMÍNIO DO TEMA 2

Autoavaliação

1. Porque a imagem profana privilegia imperatividade e sanção?
2. Distingue patologia e fisiologia jurídicas.
3. Dá três exemplos da omnipresença quotidiana do Direito.
4. Distingue coercibilidade, coação e sanção.
5. Explica a relação entre violabilidade da norma e liberdade humana.
6. Em que diferem uma visão externa e uma perspetiva intrajurídica?
7. Distingue Direito positivo, Direito vigente e Direito natural.
8. Explica como uma norma pode ser legal e contestada como ilegítima.
9. Que vantagens e riscos apresentam positivismo e jusnaturalismo?

Mini-casos

Caso	Questão
Uma norma antiga foi revogada.	É positiva? É vigente?
Um princípio de igualdade integra a Constituição.	Pode ser natural e positivo?
Um tribunal aplica uma sanção.	Onde estão imperatividade, violação e tutela?

ANTES DA AVALIAÇÃO

Checklist final

- Sei explicar o que a fenomenologia jurídica procura observar.
- Reconheço os limites da imagem profana do Direito.
- Distingo funções imperativa, protetora, preventiva e institucional.
- Defino as principais características da norma jurídica.
- Comparo olhares profanos, externos e intrajurídicos.
- Distingo Direito positivo, vigente e natural.
- Relaciono legalidade, legitimidade, segurança e Justiça.
- Comparo positivismo e jusnaturalismo com vantagens e riscos.
- Consigo estruturar uma resposta completa à questão da AF2.

Fio condutor

O Direito aparece primeiro como ordem e sanção; uma análise mais profunda revela também proteção, liberdade, institucionalidade, segurança e procura de Justiça.

Referências de estudo

Paulo Ferreira da Cunha, Teoria Geral do Direito - Uma Síntese Crítica, Livro I, Parte II, capítulos I-III; Atividade Formativa 2 e respectivas linhas orientadoras da Unidade Curricular de Introdução ao Direito.

FIM DO TEMA 2